

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

RECURSO DE APELACIÓN – INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO.

Así como se exige que las providencias judiciales (autos y sentencias) y en general los actos de la administración, en tratándose de determinaciones adoptadas a propósito de los trámites disciplinarios, sean motivadas, coherentes y lógicas, así mismo se exige que los recursos sean sustentados en forma clara, concreta, coherente y lógica.

Lo anterior nos enseña que el memorial donde se interpone el recurso debe contener un desarrollo cuya premisa mayor es el fallo o auto a controvertir, la menor, la verdad en los términos concebidos por el recurrente, y la conclusión, que es la petición de reforma o revocatoria. Argumentos que, si bien no deben ser ampulosos, no por ello podrán ser carentes de rigorismo lógico. La libertad que se plantea para el memorialista radica en la forma de expresión, en su extensión, pero no en la estructura conceptual del argumento.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó: "...No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria..."

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 112 - 115

RECURSO DE APELACIÓN – Carencia de Legitimidad para resolver el recurso propuesto.

De conformidad con lo expuesto, es claro que el recurrente en el sub lite no cumplió con la carga procesal que pendía sobre él, pues simplemente limitó su exigua sustentación en presentar una serie de afirmaciones abstractas o genéricas, sin ningún desarrollo argumentativo que permitiera conocer el verdadero fondo de su inconformidad. Señaló por ejemplo: *"...Dentro de los lineamientos de la justicia distributiva, considero que el fallo apelado adolece de inusitada drasticidad, razón por la cual lo recurro, procurando que mis razonamientos permitan el imperio de la justicia disciplinaria en segunda instancia. ..."*. Más adelante expresó: *"...De los cargos antes mencionados se tiene que el Juzgador realiza con base en las pruebas obrantes en el expediente, un falso juicio de existencia, ya que parte de las pruebas obrantes, para endilgarle la responsabilidad y conocimiento de los documentos apócrifos para ascender internamente dentro de la Dirección. ..."*. Con la primera frase, resulta imposible conocer a este despacho, cuál es el análisis que el recurrente emplea para calificar de drástico el fallo impugnado, máxime cuando la calificación de la falta y la asignación de la sanción respectiva están estrictamente ligadas a un precepto legal taxativo. Respecto a la segunda afirmación, no entiende este despacho de qué otra forma puede proferirse una decisión disciplinaria, si no es con base en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, tal como lo dispone claramente el artículo 128 del C. D. U.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 112 - 115

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2013-275
Número y fecha del fallo:	0021 del diez (10) de julio de dos mil catorce (2014)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmados.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), defensor de confianza del procesado (XXX), contra el fallo sancionatorio proferido en audiencia por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias, el pasado 5 de febrero del año en curso, dentro del expediente disciplinario 1704-01-2013-275.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

- 1.- Los hechos que originaron la presente actuación, fueron puestos en conocimiento por el Director General de la DIAN, quien dispuso la compulsación de copias, con fines disciplinarios, del acto administrativo 9918 del 3 de diciembre de 2012, a través del cual se confirmó la revocatoria del nombramiento efectuado al servidor (XXX), por no haber acreditado los requisitos para el desempeño del empleo para el cual fue designado, a pesar de haber transcurrido más de 19 años, desde la fecha de su vinculación.
- 2.- Por los hechos relatados en el numeral precedente, la Coordinación de instrucción de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, dependencia que conoció inicialmente del caso, mediante auto datado el 13 de marzo de 2013, dispuso la apertura de indagación preliminar, en contra del servidor (XXX). Esta decisión fue notificada personalmente al procesado, el 21 de junio de 2013, fecha en la cual el mismo implicado rindió versión libre sobre los hechos objeto de imputación.
- 3.- Después de practicarse algunas pruebas documentales decretadas en auto fechado el 6 de agosto de 2013, el Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, mediante auto del 6 de septiembre de 2013, ordenó la remisión del diligenciamiento con destino a esta UAE Agencia ITRC, por competencia. Las diligencias fueron avocadas por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias el 19 de septiembre de 2013.
- 4.- El 30 de septiembre de 2013, el funcionario instructor de conocimiento, declaró procedente la aplicación del procedimiento verbal dentro del diligenciamiento, razón por la cual citó al procesado a responder por las presuntas faltas gravísimas disciplinarias previstas en los numerales 1 y 56 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, posiblemente cometidas a título de dolo. En la misma decisión, se dispuso la compulsación de copias con fines penales.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

Esta decisión se notificó por edicto desfijado el 31 de octubre de 2013, tramitado mediante despacho comisorio librado ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.

5.- Ante la no comparecencia del servidor acusado, el funcionario a quo dispuso la designación de un defensor de oficio para ejercer la defensa técnica, mediante auto datado el 12 de noviembre de 2013. En este trámite, el procesado otorgó poder especial al profesional del derecho (XXX), para ejercer su defensa, a quien se le reconoció personería para actuar el 22 de noviembre de 2013.

6.- Con fecha 6 de diciembre de 2013, se dio inicio a la audiencia pública, con la presencia del procesado y su defensor de confianza. En esta ocasión el servidor acusado amplió su versión y el defensor técnico solicitó la práctica de pruebas documentales. El director de la audiencia se pronunció negativamente sobre el requerimiento probatorio, razón por la cual, el petente interpuso en el acto los recursos de reposición y apelación. El primero fue rechazado, mientras que el segundo fue concedido ante esta instancia disciplinaria.

7.- Con fecha 13 de enero de 2014 este despacho resolvió la alzada, rechazando los argumentos del impugnante y confirmando en su totalidad el auto apelado. Esta decisión se notificó por Estado del 29 de enero de 2014.

8.- Con auto del 17 de enero de 2014 el despacho de primer grado fijó el de febrero de 2014, como fecha para continuar con la vista pública. Esta decisión fue comunicada a los sujetos procesales, mediante correo electrónico.

9.- El día y hora prefijados, se dio continuación a la audiencia en las instalaciones de la Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de la ciudad de Pereira, con la asistencia y participación del abogado defensor. En esta ocasión, el despacho a quo inició por declarar cerrada la etapa probatoria del juicio, luego de lo cual, el sujeto procesal asistente presentó sus alegatos de conclusión. Finalizada la intervención del togado, el despacho profirió el fallo de instancia, a través del cual declaró al procesado responsable de incurrir en las faltas objeto de acusación. Como consecuencia, se le impuso al servidor implicado la pena de destitución e inhabilidad general de quince (15) años. Esta decisión fue notificada en estrados y al ser apelada por el defensor técnico, se le concedió un término de 2 días para sustentar su impugnación, recibándose el escrito respectivo el 7 de febrero de 2014, fecha en la cual se concedió la alzada ante este despacho de segunda instancia.

10.- El 17 de febrero de 2014 el despacho ad quem dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U., modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. Esta decisión se notificó por estado del 27 de febrero de 2014, recibándose las diligencias nuevamente en esta Dirección, el 19 de marzo de 2014, sin que las partes hubieren hecho uso de la oportunidad procesal para alegar en segunda instancia.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

El fallo de primera instancia inició haciendo un resumen detallado de la situación fáctica, soportada en el análisis de las decisiones administrativas que generaron la revocatoria del nombramiento del procesado y su consecuente retiro del servicio. Fueron referidos y evaluados igualmente, cada uno de los empleos que desempeñó el investigado al interior de la DIAN, junto con sus requisitos específicos.

Acto seguido, el funcionario de primer grado transcribió cada uno de los cargos formulados en contra del servidor disciplinado, resumiendo simultáneamente las normas que fueron infringidas con el comportamiento objeto de reproche.

En el título número 5 del fallo apelado, se resumieron cada uno de los argumentos defensivos expuestos por el procesado en su versión, así como los descargos ofrecidos por el defensor de confianza del implicado y sus alegatos de conclusión.

A partir del numeral 6, las consideraciones de la instancia estuvieron centradas en ilustrar la normatividad que soporta el marco jurídico y la competencia de esta acción disciplinaria. En el análisis probatorio y de los argumentos de la defensa, el fallador a quo, valoró los documentos allegados a la investigación, remitidos por la Coordinación de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal de la DIAN. Con base en estos documentos y en las certificaciones o respuestas emitidas por la Fundación Universitaria Los Libertadores y por el Consejo Profesional de Economía, encontró probados, en grado de certeza los cargos que fueron formulados al procesado, relacionados con el uso de documentos falsos y el suministro de datos irreales. Para el fallador, en forma certera se demostró la adecuación típica del comportamiento del procesado, dentro de los modelos abstractos constitutivos de faltas disciplinarias, preceptuados en los numerales 1 y 56 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Adicionalmente, señaló que ese comportamiento activo del enjuiciado afectó sustancialmente su deber funcional, encaminado a salvaguardar los principios de moralidad, transparencia y honradez pública, cumpliéndose así el supuesto de ilicitud sustancial. Agregó que el actuar del servidor investigado, dada su trayectoria en la función pública, denotó el conocimiento y la voluntad necesarios para corroborar que su comportamiento fue doloso.

En el título 7 del fallo impugnado, se reiteró la calificación taxativa de faltas gravísimas, que el mismo legislador asignó a los comportamientos objeto de reproche, anotando como innecesario cualquier pronunciamiento adicional relacionado con los criterios de gravedad o levedad de las faltas, señalados en el artículo 43 del C. D. U.

Finalmente, en el numeral 8 del fallo recurrido se observa el juicio de dosificación punitiva del caso, realizado conforme a los criterios de evaluación o graduación de la sanción a imponer, previstos en el artículo 47 de la LEY 734 de 2002. Fueron valorados como criterios en contra del disciplinado: el grave daño social de la conducta; el conocimiento de la ilicitud; el perjuicio patrimonial causado al Estado; y el hecho de haber infringido con la misma conducta dos disposiciones de la ley disciplinaria. A su favor, se consideraron: la ausencia de antecedentes disciplinarios; y no haber ocupado cargos directivos durante el tiempo de ocurrencia de los hechos. Con estas aseveraciones se concluyó que la sanción a imponer al procesado sería la de Destitución e Inhabilidad general por el término de quince (15) años, para ejercer funciones públicas.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es, dentro del término de dos (2) días conferido por el director de la audiencia, a partir del momento en que se realizó la lectura del fallo, el sujeto procesal presentó sus correspondiente memorial de apelación, contra la decisión de primera instancia, dentro de los cuales se pueden sintetizar los siguientes argumentos sustento de su impugnación:

En un primer argumento titulado: “FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO”, el autor del recurso expresó: “...Sobre los supuestos del fallo recurrido. Dentro de los lineamientos de la justicia distributiva, considero que el fallo apelado adolece de inusitada drasticidad, razón por la cual lo recurro, procurando que mis razonamientos permitan el imperio de la justicia disciplinaria en segunda instancia. ...”.

Un segundo planteamiento denominado “HECHOS” el profesional impugnante resumió la situación fáctica de la actuación, así como los antecedentes procesales, finalizando con una transcripción literal de los cargos objeto de acusación en contra de su defendido.

En un tercer título de sustentación definido como “ANÁLISIS” el togado recurrente aseveró: “...De los cargos antes mencionados se tiene que el Juzgador realiza con base en las pruebas obrantes en el expediente, un falso juicio de existencia, ya que parte de las pruebas obrantes, para endilgarle la responsabilidad y conocimiento de los documentos apócrifos para ascender internamente dentro de la Dirección. ...”. En el párrafo siguiente agregó: “...Para explicar la conducta en la que se enmarco la decisión sujeto de reproche es necesario definir que el falso juicio de existencia es el error del juzgador el cual está centrado en la contemplación objetiva de la prueba y no en su valoración. El juicio de existencia se define como el reconocimiento del hecho a partir de una prueba “y es falso cuando desconoce el hecho por ignorar la existencia procesal de la prueba, o lo reconoce por creer que esta obra en el proceso. ...” (Calderón 1.985)...”. Con base en la transcripción anterior, que en concepto del apelante corresponde a una jurisprudencia penal, aplicable en materia disciplinaria, el defensor en cita incluyó dos párrafos más, transcribiendo la posible definición del falso juicio de existencia por omisión y por suposición, sin realizar el más mínimo análisis de lo que sería su eventual aplicación al caso concreto.

Con relación a la calificación de la conducta, en un cuarto acápite de razonamientos, el autor de la alzada señaló: “... la conducta administrativa del señor (XXX), en su calidad de funcionario de la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales – DIAN, no puede ser endilgada a comportamiento doloso; es que ni siquiera a título de culpa puede consolidarse una inculpación justa contra mi poderdante, porque lo que realmente está demostrado es que la gestión pública del ex funcionario inculpado fue durante el tiempo de permanencia en la institución fue recta a todas luces, prueba de ello se encuentra al revisar su historia laboral, proceder que, en aras de la justicia, no puede considerarse irregular e impropio. ...En el fallo de primera instancia se quiso hacer más gravosa la situación disciplinaria de mi mandante mediante construcciones artificiosas sin sustento probatorio, que riñen contra la realidad de lo acontecido, ya que pese al hecho de que tanto la Universidad como el Consejo, hayan certificado que los documentos que aporte (sic) sean apócrifos, lo mismo no obsta para que se profese que mi defendido fue conocedor de este hecho, y por ello, haya aportado los documentos mencionados para acceder a los diferentes cargos en la DIAN; juicio realizado por el juzgador el cual propició la sanción tan gravosa, la cual no encuentra sustento jurídico, ya que tanto la constitución como la ley y la jurisprudencia han manifestado que el disciplinado goza de cierta duda, la cual le es favorable (in dubio pro reo). ... Dentro de estos lineamientos es como sostenemos, definitivamente, que por parte de mi defendido no existió comportamiento doloso, o que la conducta endilgada, en su gravedad, amerite el

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

máximo correctivo de destitución. Por ello, en el fallo impugnado no se materializa ni exterioriza aplicación de justicia distributiva.”.

En un último título relacionado con la “DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN” el impugnante señaló: “...Se evidencia que la imposición de sanción destitutoria no está acorde con los límites que señala el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pues al ser calificada como “*gravísima*”, su dosificación no puede generar la “destitución”, que está cualificada para las faltas gravísimas. ... La sanción disciplinaria, en este específico caso, en mérito de su pertinencia, debe ser gradual. Por ello reclamo para mi asistido la aplicación del precepto de que toda sanción mal impuesta debe ser modificada o revocada por el superior. ...”.

Con base en los planteamientos sintetizados y transcritos en precedencia, el abogado defensor del procesado realizó las siguientes peticiones: “...PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 75 de la Ley 734 de 2002, se digne revocar o modificar el fallo de primera instancia de fecha 5 de febrero de 2014, ...SEGUNDO: Que el fallo de segunda instancia que se profiera se me expida copia al momento de la notificación personal. ...”.

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Esta oportunidad procesal fue inutilizada por los sujetos procesales.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar a los impugnantes que de conformidad con la previsión legal consagrada en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, “...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...”.

PROBLEMA JURÍDICO : En el sub lite se trata de determinar si el abogado (XXX) cumplió con la obligada tarea de sustentar debidamente el recurso que interpuso, requisito sine qua non para que el despacho esté legitimado para abordar el examen a fondo de la alzada, y así poder emitir la determinación de rigor. O si por el contrario, en ausencia de los obligados argumentos que permitan conocer cuál es el reparo del recurrente, careciendo de legitimidad, el despacho deba rechazar la apelación propuesta.

INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO –Carencia de Legitimidad para resolver el recurso propuesto

Así como se exige que las providencias judiciales (autos y sentencias) y en general los actos de la administración, en tratándose de determinaciones adoptadas a propósito de los trámites disciplinarios, sean motivadas, coherentes y lógicas, así mismo se exige que los recursos sean sustentados en forma clara, concreta, coherente y lógica.

Lo anterior nos enseña que el memorial donde se interpone el recurso debe contener un desarrollo cuya premisa mayor es el fallo o auto a controvertir, la menor, la verdad en los términos concebidos por el recurrente, y la conclusión, que es la petición de reforma o revocatoria. Argumentos que, si bien no deben ser ampulosos, no por ello podrán ser carentes de rigorismo lógico. La libertad que se plantea para el memorialista radica en la forma de expresión, en su extensión, pero no en la estructura conceptual del argumento.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó: “..No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...”.

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado: “...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina *impugnare*, que significa “combatir, contradecir, refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación”.

Y agrega tajantemente la misma corporación : “...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como: “si hay prueba de los hechos”; “no están demostrados los hechos”; u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado” (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

En ese orden de ideas, es necesario entender, que quien apela debe preocuparse por el contenido de la decisión judicial que ataca, analizarla, revisar cual es el error en el que incurre, que normas de derecho resultan violadas con ese error, expresar claramente cuál es la trascendencia de ese error y cual el efecto jurídico que surge al ser corregido por el superior, para concluir con la pretensión de revocatoria o modificación de la providencia impugnada, circunstancias o presupuestos ausentes en el caso a examen, en donde el apelante, como se constata en el acta de audiencia, tan solo reiteró algunos limitados argumentos de sus alegaciones finales, pero dejó de lado la tarea argumentativa necesaria para que el ad quem conozca las razones específicas de la inconformidad del citado para con la determinación de primera instancia.

En efecto, en el presente evento es claro que si bien el defensor (XXX), estando dentro de la oportunidad legal, expresó su intención de impugnar el fallo, omitió cumplir con la carga procesal que le imponía el deber de señalar los motivos, las razones de hecho o de derecho que lo llevan a discrepar con la determinación del a quo, vale decir, no sustentó en forma debida el recurso de alzada incoado contra el fallo sancionatorio fechado el 5 de febrero de 2014.

Ahora bien, el Consejo de Estado¹, en materia de competencia del superior con ocasión del recurso de apelación ha sostenido :

“...En este orden de ideas resulta claro que para el juez de segunda instancia el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se

¹ Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009. Exp 16985

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de la congruencia de la sentencia, de acuerdo con el cual “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”.

La misma Corporación en pronunciamientos recientes² ha precisado respecto a la forma de sustentar el recurso de apelación:

“...De tal manera que si en el escrito presentado ante el ad-quem a modo de sustentación del recurso de apelación interpuesto no se adujo argumento alguno tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y corrección que recae sobre la sentencia de primera instancia, carece el juzgador de segunda instancia de razones para revisar dicho fallo, pues se reitera que el marco de su decisión dentro del ámbito del recurso de apelación está dado por esas argumentaciones y elementos de juicio planteados por el recurrente en la sustentación y que constituyen por lo tanto los medios de convicción por él utilizados respecto de la existencia de errores en la decisión cuestionada; obviamente, si no se esgrime crítica alguna respecto de la sentencia objeto del recurso de apelación, desconoce el ad-quem cuáles son esos errores que el recurrente considera presentes en dicha providencia, que por lo tanto deberá permanecer incólume...”

Significa todo lo anterior que resulta indispensable, al interponer el recurso de apelación en contra de una determinación, sustentarlo en debida forma, lo cual equivale a exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sirven de fundamento a la discrepancia del recurrente para con la decisión del operador disciplinario de primera instancia, contentiva del fallo sancionatorio proferido en las presentes diligencias disciplinarias.

De conformidad con lo expuesto, es claro que el recurrente en el sub lite no cumplió con la carga procesal que pendía sobre él, pues simplemente limitó su exigua sustentación en presentar una serie de afirmaciones abstractas o genéricas, sin ningún desarrollo argumentativo que permitiera conocer el verdadero fondo de su inconformidad. Señaló por ejemplo: “...Dentro de los lineamientos de la justicia distributiva, considero que el fallo apelado adolece de inusitada drasticidad, razón por la cual lo recurro, procurando que mis razonamientos permitan el imperio de la justicia disciplinaria en segunda instancia. ...”. Más adelante expresó: “...De los cargos antes mencionados se tiene que el Juzgador realiza con base en las pruebas obrantes en el expediente, un falso juicio de existencia, ya que parte de las pruebas obrantes, para endilgarle la responsabilidad y conocimiento de los documentos apócrifos para ascender internamente dentro de la Dirección. ...”. Con la primera frase, resulta imposible conocer a este despacho, cuál es el análisis que el recurrente emplea para calificar de drástico el fallo impugnado, máxime cuando la calificación de la falta y la asignación de la sanción respectiva están estrictamente ligadas a un precepto legal taxativo. Respecto a la segunda afirmación, no entiende este despacho de qué otra forma puede proferirse una decisión disciplinaria, si no es con base en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, tal como lo dispone claramente el artículo 128 del C. D. U.

Adicionalmente, debe reiterar el despacho que el apelante utilizó en su escrito de impugnación, la transcripción de ciertos apartes jurisprudenciales que hablan del falso juicio de existencia por omisión y por suposición, sin motivar siquiera cuál de estas dos posiciones o tesis es la que pretendió hacer valer en su alzada.

²Ver entre otras sentencias de la Sección Tercera: Sentencia de 14 de abril de 2010. Exp 18.115; Sentencia de 21 de febrero de 2011. Exp 17721.

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

Nótese que el apelante mantuvo huérfana la “presunta sustentación”, frente a las razones puntuales de hecho y/o de derecho, que lo llevaron a apartarse de lo resuelto por el a quo, quien por el contrario, de manera concreta y extensa realizó todo un desarrollo argumentativo y de respuesta frente a cada uno de los planteamientos defensivos invocados por los sujetos procesales. Adviértase que la construcción del fallo de primer grado estuvo soportada en la conformación de los aspectos dogmáticos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad y responsabilidad, Sin embargo el apelante nada dijo al respecto.

En la sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, la Corte Constitucional, declaró la exequibilidad de la obligación legal de “sustentar un recurso de apelación” y entre otras cosas dijo:

“...Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso...”.

Es lógico concluir que en este evento, EL DEBIDO PROCESO IMPUGNATORIO, del cual, la sustentación debida es una faceta simplemente, resultaría menoscabado en el evento de que el despacho emita decisión de fondo en segunda instancia, por carencia de competencia, en tanto no está legitimado para emitir pronunciamiento porque el recurso no fue debidamente sustentado. Por eso, es que la figura de la “sustentación debida” no es simplemente, una carga argumentativa para el recurrente, sino, también, una carga jurídica para quien decide, en la medida en que se entienda, que el superior antes de definir un recurso, debe manifestar expresamente su competencia para ello.

En ese orden de ideas, lo procedente es rechazar el recurso de apelación interpuesto porque resulta imposible pronunciarse en relación con la impugnación presentada por el togado (XXX), por carecer de los criterios fácticos y jurídicos que contradigan o refuten la decisión del a-quo, presupuesto ineludible para que este despacho adquiriera competencia y legitimidad para desatar la alzada propuesta contra el fallo sancionatorio calendarado el 4° de octubre de 2013.

En tal virtud, la Directora de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de IMPUGNACIÓN presentadas por el abogado, (XXX), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido en audiencia, del 5 de febrero de 2014, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de La Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) AÑOS PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS al ex funcionario DIAN (XXX), de condiciones civiles y personales conocidas en

Continuación del Fallo de Segunda Instancia por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primer grado proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 1704-01-2013-275.

autos, por encontrarlo responsable de incurrir en las faltas disciplinarias gravísimas, cometidas en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SÉXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

OCTAVO. Ejecutoriada materialmente esta decisión y libradas las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

NOVENO. Por la Secretaría Técnica de esta unidad y a costa del interesado, expídanse las copias del presente fallo, solicitadas por el sujeto procesal apelante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.